

1500823-66.2022.8.26.0150

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... e 18 porções de maconha no ponto de tráfico de drogas.

Outrossim, para a configuração do crime tráfico de drogas, o tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/06 traz também como elemento da traficância "transportar, trazer consigo", portanto, para a configuração do delito analisado, prescinde de flagrar o réu na efetiva comercialização dos entorpecentes, bastando para tanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500823-66.2022.8.26.0150 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500823-66.2022.8.26.0150

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235350/2022 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 27052586 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2235350 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESCLEI DE MENDONÇA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

WESCLEI DE MENDONÇA, já qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no 28 de agosto de 2022, por volta das 16h25min., na Rua Valter Dester, 434, nesta Cidade e Comarca de Cosmópolis, o denunciado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente Kennedy Wallace dos Santos, trazia consigo 32 porções de crack (aproximadamente 25g), 18 porções de maconha (aproximadamente 0.33g) e 48 porções de cocaína (aproximadamente 48g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, destinadas à entrega a terceiros, além da quantia de R\$67,00 em dinheiro.

Na audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva (fls. 67/68).

Determinada a notificação do acusado (fls. 98), efetivada às fls. 116.

Resposta à acusação (fls. 103/111).

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2022 (fls. 121/122).

Durante a instrução criminal foram inquiridas três testemunhas arroladas em comum, duas arroladas pela defesa e, por fim, o réu foi interrogado (fls. 173 e 185).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, manifestou-se pela procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa Técnica requer a improcedência da ação sustentando que as provas são precárias para viabilizar um decreto condenatório, pugnano pela absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal feita por guardas municipais por falta de amparo legal e constitucional. Requer ainda, a desclassificação do crime de tráfico para o delito de consumo pessoal. Alternativamente, em caso de condenação, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena, a fixação da pena no mínimo legal com aplicação do redutor no patamar máximo, o regime de cumprimento de pena diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilegal de entorpecentes envolvendo adolescente. Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas.

Neste sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), o boletim de ocorrência (fls. 06/10), o auto de constatação preliminar (fls. 36/37), o auto de exibição e apreensão (fls. 38/39), os laudos periciais (fls. 83/88), bem como as provas orais coligidas.

A testemunha em comum e guarda municipal Vitor Augusto Santos Costa, em juízo, narrou que em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela intensa traficância, visualizou o réu na companhia do adolescente Kennedy, sendo que o adolescente, ao perceber a presença dos agentes, arremessou uma sacola na parte de trás do beco, o que motivou a abordagem. Com o réu foi encontrado o valor de R\$67,00 e dezoito porções de maconha e com o adolescente foi localizado R\$58,00 e trinta e duas pedras de crack e ao se dirigir ao local em que foi dispensada a sacola, verificou que em seu interior havia 48 porções de cocaína, além de caderneta com anotações do tráfico. Disse que já conhecia o réu de outras abordagens. Respondeu que o que motivou a abordagem ao réu foi o fato de o adolescente que estava junto com o réu arremessar a sacola após ter visto os agentes; que jamais viu o seu colega de farda ameaçar o réu.

Seguindo a mesma diretriz, foram as palavras da testemunha em comum e guarda municipal Eliseu Mendes Moreira. Respondeu que a sacola com as drogas foi jogada em cima do telhado; que nunca visualizou o réu usando drogas no local.

O adolescente Kennedy, em juízo, disse que conhece o réu da favela aonde moram.

Narrou que no dia dos fatos estava vendendo drogas no ponto e que o réu estava passando pelo local no momento da abordagem policial, mas não vendeu drogas para ele. Respondeu que no dia dos fatos havia outras pessoas vendendo drogas no local; que quando foi abordado pelos guardas, juntamente com réu, os guardas disseram que a casa havia caído para eles.

A testemunha de defesa Maria Luciana de Mendonça, mãe do réu, em juízo, narrou que o filho é usuário de maconha desde os 12 anos e nunca conseguiu encaminhar o filho para tratamento e que ele trabalhava à época dos fatos. Respondeu que o réu não estava morando com ela, mas sabia que ele trabalhava das sete da manhã às cinco da tarde; que ele já foi preso por tráfico de drogas.

A testemunha de defesa Vitoria Melo Neves, em juízo, narrou que presenciou a abordagem do réu pelos guardas municipais. Disse que viu o momento em que o réu desceu ao ponto para comprar drogas e em seguida viu os GM's subindo com réu e ouviu os guardas dizerem que iam levar o réu para averiguação. Disse que via diariamente o réu descer ao ponto para comprar drogas. Respondeu que conhecia o réu

de vista; que a esposa do réu lhe procurou pedindo ajuda; que via ele descer para comprar drogas; que ele trabalhava, mas não via ele descer a rua para ir trabalhar; que trabalha de segunda a sexta-feira na casa de sua tia cuidando dos filhos dela; questionada sobre a ocorrência dos fatos em um domingo, disse que às vezes sua tia faz uns bicos em finais de semana.

O acusado, em seu interrogatório em juízo, negou a autoria dos fatos. Afirmou que estava apenas passando pelo beco, indo a casa de uma colega, quando ocorreu um corre-corre na rua e foi abordado pelo policial Vítor, que o revistou. Em seguida viu subir a rua o guarda Eliseu com o adolescente Kennedy e foi informado que seria encaminhado a delegacia para averiguação. Posteriormente, a polícia apareceu com uma sacola de drogas. Disse que não tinha nenhum real com ele, nem as porções de maconha e não estava na companhia do adolescente. Respondeu que conhece o adolescente só de vista; que já conhecia os guardas Vítor e Eliseu de outras abordagens; que já foi ameaçado pelo GM Eliseu várias vezes, o qual dizia que "uma hora a casa vai cair"; que é usuário de maconha desde os 12 anos de idade; que usava diariamente umas dez buchas de maconha.

Em que pese a negativa de responsabilidade pelo crime esta veio desacompanhada de provas. O réu apresentou versão frágil e pueril, cuja veracidade não foi capaz de comprovar, como lhe competia, nos termos do que prevê o art. 156 do Código de Processo Penal e, portanto, tal versão não deve prevalecer quando em confronto com as provas produzidas nos autos, restando sua negativa isolada do conjunto probatório.

Aliás, acatar a falaciosa fala do réu implicaria reconhecer que houve verdadeiro conluio criminoso engendrado pelos agentes com o intuito exclusivo de incriminar pessoa que sabiam ser inocente e, da mesma forma, sem a mínima comprovação.

É sempre bom consignar que os esclarecimentos apresentados pelos policiais são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, eles prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada existindo prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos.

No tocante ao depoimento de agentes da Lei, o Egrégio Tribunal tem entendido:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286).

Os agentes responsáveis pela abordagem e prisão do réu, ao serem ouvidos em juízo, disseram que flagraram o acusado na companhia do adolescente Kennedy no ponto de venda drogas e, ao abordarem o réu, com ele encontraram R\$67,00 em dinheiro e 18 porções de maconha, corroborando suas declarações em solo policial.

Em que pese o adolescente tenha confessado em juízo que estava traficando no local e dito que pouco antes da abordagem dos agentes da lei encontrou-se com o réu inadvertidamente, mas que não vendeu drogas para ele, sua versão não convence porque contrária a versão prestada em solo policial (fls. 13), ocasião em que relatou "que foi comprar maconha pois é usuário de drogas, e nisso encontrou Wescley, então logo foi abordado pela polícia. Que ficaram parados e não correram da viatura da ROMU. Disse que estava subindo o beco, e a ROMU só encontrou a droga no final do beco, momento em que a GCM alegou ser de propriedade dele e de Wescley. Que quando foi realizada a abordagem nele, nada foi encontrada, apenas seu celular. Que é apenas usuário de droga, e não tem envolvimento com o tráfico. [...]". Tal versão, enfraquece e retira a credibilidade de suas declarações em juízo, consubstanciando-se em verdadeira tentativa de inocentar o réu.

O réu, por sua vez, declarou em juízo que estava indo a casa de uma amiga, quando houve um corre-corre na viela e em seguida foi abordado pelo GM Vítor.

Posteriormente, o GM Eliseu apareceu detendo o adolescente Kennedy, o que demonstra mais contradições nas declarações do adolescente e do réu em juízo uma vez que o adolescente disse que estava na companhia do réu no momento da abordagem, após o

encontrar por acaso na rua.

Para além dessas considerações, a Defesa não produziu provas de que o acusado estivesse no local apenas para comprar drogas. A única testemunha para corroborar essa versão, a testemunha de defesa Vitoria, disse que no dia dos fatos viu o réu descer ao ponto para comprar drogas, como fazia diariamente, e em seguida disse ter visto os GM's subindo com réu detido. Todavia, afirmou que conhecia o réu apenas de vista e que a esposa do réu, após os fatos, lhe procurou pedindo ajuda o que diminui em muito a credibilidade de suas declarações.

Nesse cenário, não prospera a tese da Defesa Técnica de que as provas são fracas para viabilizar um decreto condenatório, reforçando que o réu não estava traficando no local, porquanto, ainda que o réu não tenha sido flagrado em atos de efetiva venda das drogas, carregava consigo quantia em dinheiro e 18 porções de maconha no ponto de tráfico de drogas.

Outrossim, para a configuração do crime tráfico de drogas, o tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/06 traz também como elemento da traficância "transportar, trazer consigo", portanto, para a configuração do delito analisado, prescinde de flagrar o réu na efetiva comercialização dos entorpecentes, bastando para tanto que o acusado transporte ou traga consigo tais substâncias ilegais, sendo esse, precisamente, o caso dos autos.

Quanto a eventual possibilidade de desclassificação para o delito previsto no topo do art. 28 da Lei 11.343/06, lembro que o § 2º deste dispositivo diz que para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso, a quantidade de drogas apreendidas com o réu e o adolescente, além da folha de anotação do tráfico, a abordagem em local conhecido como ponto de tráfico, indicam que a posse não era para o mero uso, mas tinha finalidade comercial.

Outrossim, também não prospera a alegação da ilicitude da busca pessoal feita por guardas municipais, sob o argumento de que é vedado pela Constituição Federal aos guardas municipais exercer atividade típica de polícia.

Em que pesem os argumentos da Defesa Técnica, a atuação da guarda municipal em defesa da segurança social e do patrimônio público encontra respaldo no permissivo legal insculpido no artigo 301 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL-CPP. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal-CPP. 2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de reconhecer que as substâncias entorpecentes apreendidas seriam para o consumo do paciente, demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita. 3. Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolhido regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 603.686/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021). grifei

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE GUARDA MUNICIPAL NÃO TEM PODER DE POLÍCIA. Inocorrência. Mesmo não sendo a prisão atribuição dos Guardas Municipais prevista constitucionalmente, trata-se de ato legal, em proteção à segurança social, razão pela qual não resta eivada de nulidade. Se qualquer do

povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar-se em proibição ao guarda municipal de proceder a prisão. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Palavras dos policiais corroborada por outros elementos de provas. Tipo legal incriminador que se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma na outra desde a sua produção até a sua entrega a consumo, ainda que de forma gratuita. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. (139843220098260068 SP, Relator: Machado de Andrade, Data de Julgamento: 16/12/2010, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/12/2010). grifei

Portanto, ainda que a prisão não seja atribuição constitucional dos guardas municipais, trata-se de ato legal para coibir a prática de delito em curso, sendo esse precisamente o caso dos autos. Assim, com fulcro no artigo 301 do Código de Processo Penal, tratando-se de flagrante delito, cabe a qualquer do povo efetuar a prisão do indivíduo em conflito com a lei, ou ao menos tentar deter a atividade criminosa, eis que o acusado foi abordado no ponto de tráfico, com dinheiro e 18 porções de maconha em sua posse direta e na companhia de um adolescente, que no momento da abordagem dispensou uma sacola contendo mais substâncias entorpecentes e folhas de anotação do tráfico.

Por fim, também restou incontroverso que o crime praticado pelo acusado envolveu adolescente, uma vez que ambos foram flagrados na posse dos entorpecentes, devendo assim, o réu se submeter ao aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do fato está devidamente evidenciada pelo auto de constatação e pelo laudo de substância psicoativa (fls. 83/85), segundo o qual as substâncias apreendidas tratavam-se de entorpecentes.

Já a autoria restou presente uma vez que parte dos ilícitos foram encontrados na posse direta do acusado, além de quantia em dinheiro, conforme prova oral produzida sob o manto do contraditório e ampla defesa, a qual não foi afastada ante a ausência de provas em sentido contrário.

A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas tornam irrefutável a conclusão de que, no dia, horário e local indicados na peça acusatória, o acusado trazia consigo, para venda e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade." (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498).

Portanto, a conduta por ele praticada encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, atenta ao artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, verifico, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, que a quantidade das drogas apreendidas com o réu não se mostra excessiva a permitir a fixação da pena acima do mínimo legal, sendo assim, na primeira fase, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, em CINCO ANOS de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, por ser o réu reincidente (fls. 57/59), com base no artigo 61, inciso I, do Código Penal, agravo-lhe as penas em 1/6, o que resulta em CINCO ANOS e DEZ MESES de reclusão e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo, 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, pois a prática do crime atingiu adolescente, razão pela qual aumento a pena em 1/6 o que resulta em SEIS ANOS, NOVE MESES e VINTE DIAS de reclusão e no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Nessa mesma fase, considerando que réu não é primário, pois ostenta condenação definitiva, inclusive por crime de mesma natureza (fls. 57/59), entendo presentes indícios de que o réu se dedica à atividade criminosa, portanto, não sendo cabível a redução da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Por fim, tendo em vista os antecedentes do réu e o montante de pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o denunciado WESCLEI DE MENDONÇA ao cumprimento das penas de SEIS ANOS, NOVE MESES e VINTE DIAS de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário, pela prática do delito definido no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O acusado foi preso em flagrante, teve sua prisão convertida em preventiva e assim vem respondendo aos autos, não poderá, portanto, recorrer em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Determino, ainda, o perdimento definitivo dos valores apreendidos obtidos com a traficância, nos termos do artigo 91 II, "b", do Código Penal, e do artigo 62 da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Transitada em julgado e, nada mais sendo requerido, oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cosmopolis, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA